

1500118-11.2022.8.26.0363

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Gomes de Queiroz Coutinho

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... tinha em depósito, para fins de tráfico e nas imediações de estabelecimento de ensino, 213 (duzentas e treze) porções de cocaína.

De acordo com a denúncia, Guardas Municipais que realizavam patrulhamento preventivo de rotina receberam denúncia anônima (feita por um transeunte) que atribuía o tráfico de drogas ao conduto de um veículo GM/Vectra com placa COH-0827.
...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

1ª Vara

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi Mirim-SP - cep 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500118-11.2022.8.26.0363 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500118-11.2022.8.26.0363

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2022366/2022 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 22634315 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 225/22/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2022366 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2022366/2022 - DEL.POL.MOGI-MIRIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO APARECIDO CIRILO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Gomes de Queiroz Coutinho

VISTOS:

ADRIANO APARECIDO CIRILO, já qualificado na ação penal em epígrafe, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 25 de janeiro de 2022, por volta das 16:00 horas, na Rua Graciliano Oliveira Fernandes, altura do nº 88, bairro Novacoop, neste Município e Comarca de Mogi Mirim, tinha em depósito, para fins de tráfico e nas imediações de estabelecimento de ensino, 213 (duzentas e treze) porções de cocaína.

De acordo com a denúncia, Guardas Municipais que realizavam patrulhamento preventivo de rotina receberam denúncia anônima (feita por um transeunte) que

atribuía o tráfico de drogas ao conduto de um veículo GM/Vectra com placa COH-0827. Diante do relato e, mais que isso, da pesquisa feita a partir do emplacamento do automóvel, dirigiram-se à casa do suspeito. Tão logo chegaram no local, visualizaram o acusado defronte ao imóvel e ao lado do veículo mencionado no informe apócrifo adrede recebido. O suspeito foi então esclarecido o teor da denúncia anônima e, embora tenha negado o tráfico num primeiro momento, logo acabou por confessar a prática do crime e exibir aos agentes públicos um capacete donde retirou 213 (duzentas e treze) porções de cocaína prontas para a venda.

O Inquérito Policial encontra-se nas fls. 01/64 e vem instruído com o auto de prisão em flagrante, com o boletim de ocorrência alusivo aos fatos, com os autos de exibição e apreensão e de constatação preliminar, e com o Relatório da Autoridade Policial.

O acusado foi então regularmente notificado e apresentou resposta escrita (fls. 109, 127 e 131/132).

Recebida a denúncia, seguiu-se a citação pessoal (fls. 139/141 e 158).

Na audiência atermada a fls. 162/163 interrogou-se o réu, ouviram-se 02 (dois) testemunhas. Quando dos debates, o D. Promotor de Justiça requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. O I. Defensor constituído arguiu a ilicitude da prova; no mérito, postulou a absolvição do réu e, subsidiariamente, não apenas a fixação da pena em seu patamar mínimo, mas também o afastamento da causa de aumento de pena inscrita no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06, o reconhecimento da causa de diminuição de pena inscrita no artigo 33, § 4º, daquele diploma legal, a adoção de regime inicial aberto e, finalmente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Relatados, D E C I D O :

Cuida-se de tráfico de entorpecentes (perpetrado nas imediações de estabelecimento de ensino), delito tipificado no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

A pretensão punitiva posta na denúncia é mesmo procedente.

Enquanto a materialidade descende da prova consubstanciada no auto de exibição e apreensão e nos laudos periciais encartados a fls. 09, 118/120 e 121/125, a autoria restou suficientemente demonstrada com os depoimentos prestados pelas testemunhas de forma segura e coesa, sem dúvidas ou contradições capazes de recomendar algum descrédito.

Como se infere do incluso inquérito policial, Guardas Municipais que realizavam patrulhamento preventivo de rotina receberam denúncia anônima (feita por um transeunte) que atribuía o tráfico de drogas ao conduto de um veículo GM/Vectra com placa COH-0827. Diante do relato e, mais que isso, da pesquisa feita a partir do emplacamento do automóvel, dirigiram-se à casa do suspeito. Tão logo chegaram no local, visualizaram o acusado defronte ao imóvel e ao lado do veículo mencionado no informe apócrifo adrede recebido. O suspeito foi então esclarecido o teor da denúncia anônima e, embora tenha negado o tráfico num primeiro momento, logo acabou por confessar a prática do crime e exibir aos agentes públicos um capacete donde retirou 213 (duzentas e treze) porções de cocaína prontas para a venda.

Quando ouvidos durante a instrução criminal, os Guardas Municipais César Francisco Pereira e Pedro Felipe Delatorre Mosca ratificaram os relatos antes dados ao Delegado de Polícia que presidiu a lavratura do auto de prisão em flagrante; reafirmaram não apenas o recebimento daquela denúncia deveras minunciosa que justificou e deu razão de ser à ação policial, mas também a abordagem do acusado

defronte à residência e, principalmente, a apreensão da droga no exato local apontado pelo próprio réu (interior de um capacete guardado na parte externa da casa).

E a despeito do entendimento comumente esposado em casos deste jaez, não há como inquirir a validade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais (raciocínio extensível aos membros das Guardas Municipais), mormente quando ausente qualquer fato concreto, mínimo que seja, que sugira ou recomende algum descrédito. É que a simples condição de Policial (ou Guarda Municipal) não autoriza conclusão sobre parcialidade ou falta de isenção capaz de infirmar os respectivos relatos, quiçá sobre a sugerida predisposição de imputar crimes a inocentes. Trago à colação v. aresto do C. Supremo Tribunal Federal, relator o eminente Ministro CELSO de MELLO:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC n. 74.608-0 – SP).

Confirmam-se ainda, porque pertinentes, os seguintes julgados do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte (STJ - REsp. 751.760/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 18.10.2005. DJ 14.11.2005, p. 400).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. (...) 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (STJ - AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental não provido.

PROVA CRIMINAL – Depoimento de Policial – Validade – Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. Segurança nas versões apresentadas – Recurso provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra, desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador (Apelação Criminal n. 185.484-3 – São Paulo – 6ª Câmara Criminal – Relator: Djalma Lofrano – 22.06.95).

PROVA CRIMINAL – Hipótese de tóxico – Depoimento prestado por policial – Admissibilidade – Relato que não deixa dúvida alguma do encontro de maconha em poder do agente – Condenação mantida. O agente da polícia serve como testemunha, tal qual qualquer outra pessoa, até porque ele é auxiliar da Justiça criminal e não é de supor-se que se transforme em parte, que compareça a Juízo para perseguir pessoas inocentes, para as quais criam crimes inexistentes (Apelação Criminal n. 159.299-3 – Botucatu – Relator: Djalma Lofrano – 18.08.94).

PROVA CRIMINAL – Testemunhal – Depoimento de policial – Validade – Recurso não provido. O depoimento de policial assume força probante incriminadora, uma vez que,

como qualquer pessoa, o policial pode servir como testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade, notadamente se não há elementos indicadores de que tenha ele se desviado do exercício de sua função pública, da qual decorre presunção juris tantum de legitimidade de sua atuação (Apelação Criminal n. 172.521 - São Paulo - 4a Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 12.06.95).

Aliás, "seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito" (Apelação n. 1.002.771/3, SP, 11a Câmara - Relator: Xavier de Aquino).

Então, denúncia anônima (feita por um popular) não apenas atribui o tráfico de drogas a uma determinada pessoa, mas também descreve as características do suspeito, indica o veículo automotor por ele utilizado e seu endereço. Guardas Municipais se dirigirem ao exato local mencionado naquele informe e encontram a exata pessoa nele mencionada ao lado do exato veículo nela mencionado. A despeito de negar inicialmente a prática do crime, o acusado acaba por confessar a guarda de drogas e, mais que isso, aponta aos agentes públicos um capacete onde de fato se apreendem nada menos que 213 porções de cocaína.

Ora, tangencia a mais cândida ingenuidade ignorar tão íntima relação entre os fatos e acreditar, sinceramente, estar-se diante de mera e singela coincidência, ou de "invenção" de Guardas Municipais que não apenas urdiram trama tão sórdida quanto bem concatenada, mas também providenciaram relevantes porções de cocaína para forjar a prisão e incriminar pessoa inocente, proba, trabalhadora e, pasmem, absolutamente desconhecida!

A negativa expendida pelo acusado por ocasião de seu interrogatório judicial, então, restou absolutamente isolada e, por isso mesmo, sem a mais vaga e remota aptidão para infirmar os relatos assaz sólidos produzidos em seu desfavor.

É que o acusado se limitou a negar a posse de tantas e quantas porções de cocaína sem, contudo, trazer aos autos quaisquer elementos concretos - mínimos que sejam - que abonem a tese da falsa imputação.

Aquela arguição de ilicitude de prova pela suposta falta de consentimento do morador, de resto, não tem qualquer relevância jurídica. O crime de tráfico de drogas é daqueles ditos permanentes, cujo momento consumativo se protraí no tempo. Daí situação de flagrância que legitimava o ingresso dos agentes públicos no imóvel independentemente do consentimento do morador, mormente se considerada a fundada suspeita que efetiva e concretamente existia mercê da denúncia anônima deveras minuciosa adrede recebida. Reporto-me, uma vez mais, à jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRELIMINARES - Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva - Cerceamento de defesa por inobservância do artigo 384, § 2º, do CPP. Inocorrência. Denúncia aditada pelo Parquet apenas para sanar erro material. Questão não aventada pela defesa no momento oportuno. Preclusão. Prejuízo não demonstrado. Princípio do pas nullité sans grief - Ilicitude da prova. Invasão de domicílio não configurada. Crime permanente e estado de flagrante. Fundada suspeita evidenciada - Rejeição. MÉRITO - Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (117 porções de cocaína, com peso líquido de 46,5 gramas), além de dinheiro, 02 aparelhos celulares e anotações alusivas ao tráfico - Violação ao artigo 155 do CPP não caracterizada - Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei de Drogas demonstrada (envolvimento de adolescente) - Condenação mantida. PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO - Bases nos patamares - Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei de Drogas. Elevação de 1/6 - Inviável o redutor do

§ 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Regime inicial fechado - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) - Decretado o perdimento dos valores apreendidos em favor da União - Apelo provido em parte apenas para corrigir a capitulação do delito (Apelação Criminal 1500108-69.2021.8.26.0599; Relator: Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - Data do Julgamento: 24/11/2021). Destaquei.

HABEAS CORPUS - Tráfico de droga - Prisão preventiva suficientemente fundamentada - Alegação de invasão de domicílio - Não ocorrência - Não é exigível a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso no local, uma vez que a prisão em flagrante deu-se por crime permanente - Alegação de nulidade de provas - Impossibilidade - É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas (STF) - Insuficiência de medidas cautelares alternativas - Condições pessoais favoráveis não têm o condão, de per se, ensejar a liberdade - Alegação que demanda análise aprofundada de elemento de prova, não cabível em sede de habeas corpus - A decretação da prisão preventiva não exige juízo de certeza, próprio da sentença condenatória - A quantidade de estupefaciente não pode beneficiar o paciente - Análise da situação de pandemia causada pela COVID-19 que não autoriza liberdade no caso concreto - Liberdade incabível - ORDEM DENEGADA (Habeas Corpus Criminal 2197072-29.2021.8.26.0000; Relator: Adilson Paukoski Simoni; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - Data do Julgamento: 17/11/2021).

CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 "CAPUT", DA LEI 11.343/06). APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS. PREJUDICIAL - NULIDADE - ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGADA ILICITUDE DA PROVA - INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL - INOCORRÊNCIA - CONDUTA POLICIAL REVESTIDA DE LICITUDE, CONSTATANDO-SE RAZÕES FUNDADAS PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO ATÉ PORQUE SE CUIDOU DE CRIME PERMANENTE - PRECEDENTE - NULIDADE AFASTADA. TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E CONDIÇÕES DO FLAGRANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS - CRITERIOSAMENTE FIXADAS, OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL - DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO REDUTOR, AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS - REGIME FECHADO MANTIDO - SUBSTITUIÇÃO DAS REPRIMENDAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSI" DESCABIDOS - RECURSO DESPROVIDO (Apelação Criminal 1500336-65.2020.8.26.0571; Relatora: Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - Data do Julgamento: 17/11/2021). Destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Preliminar - Alegação de nulidade decorrente de invasão de domicílio - Inocorrência - Crime permanente, de consumação prolongada no tempo - Depoimentos de policiais no sentido da existência de fundadas suspeitas da prática delitiva pelo acusado, decorrentes de denúncias anônimas e investigações prévias - Presença da situação flagrancial que prescinde de autorização judicial - Ausência da aventada nulidade - Preliminar rejeitada. Mérito - Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas no decorrer da instrução, tanto que sequer foram questionadas pela defesa - Condenação mantida - Dosimetria - Reconhecimento da atenuante da confissão - Pretensão prejudicada, porquanto já alcançada em primeiro grau - Pretendida mitigação da pena em patamar máximo, pelo reconhecimento do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas - Impossibilidade - Quantidade de droga apreendida utilizada apenas na terceira fase do cálculo, para modular a redução da citada causa de diminuição - Manutenção da fração de minoração de 1/2 imposta em primeiro grau, diante da quantidade e da nocividade dos entorpecentes apreendidos em poder do acusado (394 porções de 'crack', pesando 35,55 gramas e 35 porções de 'cocaína', pesando 9,28 gramas) -

Regime aberto que encontra arrimo no art. 33, §2º, 'c', do CP – Recurso desprovido (Apelação Criminal 1500258-07.2021.8.26.0581; Relator: Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Manuel - Data do Julgamento: 17/11/2021). Destaquei.

Aquela pequena contradição destacada nas alegações finais da Defesa, porque incidente sobre dado periférico e, bem por isso, sem maior relevância ao desfecho da demanda, nem têm o condão de infirmar a certeza da materialidade e autoria delitiva.

É até intuitiva a existência de alguma divergência entre os depoimentos colhidos no inquérito e na ação penal: a uma, pois o só transcurso de certo hiato temporal contribui para que as descrições fáticas não sejam rigorosamente idênticas; a duas, pois a colheita de tais relatos é presidida por pessoas distintas (Delegado de Polícia e Juiz de Direito), que não apenas formulam perguntas de forma não rigorosamente idênticas, mas também, e principalmente, reproduzem as respostas com os detalhes e impressões que cada um cuidou de aferir.

E tanto assim o é que a E. 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou, nos autos da apelação nº 993.07.093495-6, da Comarca de Mogi Mirim, relator o eminente Desembargador Antonio Luiz Pires Neto, que divergências habilmente pinçadas pela defesa nos depoimentos, ao contrário de pôr em dúvida a veracidade deles, servem para dar-lhes maior valor, o que reforça o entendimento de que não havia mesmo nenhum interesse em prejudicar o réu, pois, em caso contrário, bastaria que houvessem combinado e ensaiado entre si o que deveriam dizer perante o Magistrado e seus depoimentos seriam coincidentes, sem divergência alguma, adrede preparados para (aí sim) incriminar alguém indevidamente...

E aqui, repita-se, a única “inconsistência” diz respeito à forma como agentes públicos teriam identificado o endereço do réu: menção expressa pelo munícipe que acionara a Guarda Municipal ou pesquisa da placa do veículo que tal munícipe mencionara. Só.

Num caso e no outro, porém, inexiste dúvida alguma sobre ser mesmo do réu o imóvel onde as numerosas – numerosas mesmo – porções de cocaína em testilha.

E fixada a posse do acusado sobre a droga, nem se faz necessária maior digressão, outrossim, para afastar a subsunção da conduta dos acusados à regra do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

À preexistência de denúncia anônima minunciosa (que fazia menção expressa ao tráfico, identificava o acusado, seu endereço e veículo automotor), somam-se a quantidade de substância entorpecente apreendida (nada menos que 213 porções de cocaína), a forma de acondicionamento (porções embaladas de forma individualizada e, por isso mesmo, assaz propícia ao comércio) e, finalmente, a inexistência de qualquer menção pelo réu de finalidade diversa (qual seja, consumo próprio).

É, pois, o quantum satis.

Não é caso, contudo, do perdimento querido pelo Ministério Público, pois a droga não estava no interior do veículo, senão da residência, e não houve segura comprovação da efetiva e concreta utilização do bem como instrumento para o tráfico de drogas.

ADRIANO APARECIDO CIRILO, então, praticou fato antijurídico, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a respectiva sanção penal que passo a dosar.

Em atenção ao preceito contido nos artigos 42 da Lei nº 11.343/06 e 59 do Código

Penal, cumpre notar a inexistência de antecedentes criminais. Não há se olvidar, porém, a quantidade e a natureza da droga apreendida (nada menos que 213 porções de cocaína). Debuxa-se daí não apenas maior lesão ao interesse jurídico tutelado pela norma, mas também, e principalmente, maior culpabilidade e maior reprovabilidade da conduta. Ora, são sabidos, plenamente sabidos, os malefícios advindos de tais substâncias, assim como a estreita relação existente entre o comércio de drogas e os mais variados e graves crimes. Justifica-se, pois, o arbitramento de pena acima no mínimo legal, compatíveis com tais circunstâncias, sob pena de se dispensar a ele tratamento idêntico àquele merecido por pessoas que tem em depósito, para o consumo de terceiros, quantias bem menos significativas. Reporto-me, uma vez mais, à jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

A quantidade de drogas apreendida pode e deve ser utilizada na dosimetria (STJ - HC - 10.165 - Rel. Félix Fischer - j. 9.11.1999 - DJU 14.2.2000, p. 53).

Ao proceder a individualização da pena, o Juiz após aferir um leque de circunstâncias de natureza subjetiva - culpabilidade, antecedentes, conduta social, e personalidade do agente - e de natureza objetiva - motivos, circunstâncias e conseqüências do crime -, fixará aquela aplicável dentre as cominadas, em quantidade que for necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, definindo, a seguir, o regime inicial de cumprimento de pena, a qual não deve ser excessiva, nem demasiadamente abrandada, mas justa, adequada e idônea, em qualidade e quantidade suficientes para reprimir a prática da infração e promover a tutela da sociedade (STJ - 6a Turma - REsp. 90.171 - Rel. Luiz Vicente Cernichiaro - j. 08.10.1997 - DJU 12.08.1997, p. 36.287).

Para a exarcebação é permitido ao juiz, diante das circunstâncias judiciais, apreciar o alto grau de reprovabilidade da conduta (STJ - 5a Turma - Rel. José Arnaldo da Fonseca - REsp. 195.222 - j. 02.09.1999 - DJU 11.10.1999, p. 83, e RT 773/552).

Com tais premissas, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Não há circunstância agravantes ou atenuantes.

Com relação às causas de aumento de pena, dá-se que tráfico foi cometido nas imediações de estabelecimento de ensino (EMEB - Vereadora Terezinha da Silva Oliveira), consoante o croqui constante da denúncia e laudo acostado a fls. 121/125, advindo daí perfeita subsunção do fato àquela norma inserta no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06. Faz-se, então, derradeiro acréscimo, à razão de 1/6 (um sexto), de modo a alcançar 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Não há, por fim, causas gerais ou especiais diminuição de pena, pois a despeito da primariedade "técnica" (a condenação anterior foi seguida de formal pronunciamento de prescrição), reiterada jurisprudência tem afastado a incidência do redutor previsto no § 4º naqueles casos em que as circunstâncias do delito evidenciam que o acusado se dedicava a atividades criminosas. Quando do julgamento do AgRg no AREsp 628.686/MG, assentou a Colenda 6ª Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, relatora a eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos em poder do acusado constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à minguada do preenchimento dos requisitos legais". Destaquei.

No mesmo sentido o v. aresto proferido nos autos do HC 484.129/SP, relator o eminente Ministro Felix Fischer, para quem não se pode desprezar que "(...) na

ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes" (STJ, HC 484.129/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). Destaquei.

Confira-se ainda, porque relevante, trecho do v. acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

(...) Ademais, em razão da diversidade, da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, deixo de aplicar a causa especial de redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado). Com efeito, foram apreendidos 248,66 gramas de maconha e 4,68 gramas de cocaína na forma de crack (fls. 152/156, 235/239, 241/ 245 e 250/254). Deveras, não somente a natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos indicam a impossibilidade da concessão do benefício, mas também a sua quantidade, forma de acondicionamento e peso líquido e as circunstâncias que cercaram a apreensão do entorpecente, após denúncia anônima. Tais elementos de prova demonstram que não se trata de traficância inédita, que pudesse qualificar o apelante como "traficante de primeira viagem" ou "pequeno traficante" (aquele que comercializa drogas apenas para sustento do próprio vício ou subsistência básica), mesmo porque não se obtém tal monta, variedade e tipo de entorpecente em qualquer canto de uma biqueira, muito menos se confia tal quantidade de droga a alguém que não tenha alcançado o mínimo de confiabilidade dentro da cadeia do tráfico (...) (Apelação Criminal nº 0012097-81.2015.8.26.0624, da Comarca de Tatuí - 15ª Câmara de Direito Criminal - Relatora: Gilda Alves Barbosa Diodatti - 13/06/2019). Destaquei.

E aqui, repita-se, não bastasse a circunstância de o conhecimento do fato (tráfico) por terceira pessoa (popular que acionou a Guarda Municipal) por si só sugerir a repetição de atos capazes de permitir a constatação pelos moradores da região, a quantidade de droga apreendida (nada menos que 213 porções de cocaína) tornam pouco crível imaginar seja a primeira incursão do indiciado no comércio ilícito de entorpecentes. Difícil, senão impossível, ignorar sua dedicação a atividade criminosa (mormente se considerada a propriedade de veículo automotor a despeito da inexistência de qualquer comprovação de atividade lícita que propiciasse a renda necessária para a aquisição e manutenção), motivo bastante para afastar a aplicação do redutor...

Torno definitiva a pena privativa de liberdade, dessarte, em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Fixo a pena pecuniária em 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, resultado da previsão legal mínimas para o delito (500) modificada, na mesma proporção, pelos acréscimos fomentados pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis (natureza e quantidade de droga) e pela causa de aumento de pena (crime perpetrado nas imediações de estabelecimento de ensino). Arbitro o valor unitário do dia multa no mínimo legal, qual seja, um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, corrigido monetariamente até a presente data, à míngua de maiores dados acerca da capacidade financeira do réu.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA posta na denúncia e CONDENO ADRIANO APARECIDO CIRILO, já qualificado nos autos, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como no pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06.

Ausentes os requisitos autorizadores, deixa-se de substituir a pena privativa de

liberdade imposta por aquelas restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal). O crime perpetrado pelo réu é deveras grave e, por isso mesmo, nem guarda compatibilidade com aquelas sanções mais brandas previstas no sobredito dispositivo legal. Quando do julgamento do Habeas Corpus nº 203.403/SP, aliás, a 5ª Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, relator o eminente Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, assentou que não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou (HC 203.403/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011).

No mesmo sentido o v. aresto proferido em data deveras recente pela C. 4ª Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da apelação nº 0020420-98.2010.8.26.0576, relator o eminente Desembargador Salles Abreu, para quem atualmente, o entendimento majoritário do Colendo Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei 11.343/06, possibilitando, em um caso concreto, a conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. No entanto, o crime continua grave e hediondo, sendo que a substituição penal não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do delito, portanto, não deverá ser aplicada no caso em tela, afastado o pedido subsidiário (Apelação nº 0020420-98.2010.8.26.0576 – São José do Rio Preto – 4ª Câmara Criminal – Relator: Salles Abreu – 04/10/2011).

E ainda:

PENA – Restritivas de direitos – Tráfico de entorpecentes – Incompatibilidade com a determinação legal de regime fechado (art. 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90) – Inaplicabilidade dos benefícios da Lei nº 9.715/98 – Recurso improvido (Apelação Criminal nº 877.915-3/8 – São Paulo – 6ª Câmara Criminal – Relator: Marco Antonio – 17/08/2006).

PENA – Restritivas de direitos – Réu condenado por tráfico de entorpecentes – Substituição da reprimenda privativa de liberdade – Inadmissibilidade – Preliminares rejeitadas e recurso improvido (Apelação Criminal nº 908.095.3/3 – São Paulo – 9ª Câmara Criminal – Relator: Ubiratan de Arruda – 27/09/2006).

Não tem o acusado direito, outrossim, à suspensão condicional da pena (artigo 77 do mesmo Diploma Legal).

E cuidando-se de crime equiparado àqueles ditos “hediondos”, o regime inicial de cumprimento das penas de reclusão há de ser o fechado.

A despeito disso e, mercê da concessão de Habeas Corpus pela E. Superior Instância (registro nº 2015847-42.2022.8.26.0000, cujo trâmite se deu perante a C. 16ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo), faculto o apelo em liberdade, observadas eventuais medidas cautelares fixadas naqueles autos.

Expeça-se ofício ao IIRGD comunicando a presente decisão para as anotações pertinentes. Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o correlato mandado de prisão.

Custas e despesas ex lege (artigo 4º, § 9º, “a”, da Lei nº 11.608/03).

P.R.I.C.

Mogi Mirim, 09 de maio de 2022.

EMERSON GOMES DE QUEIROZ COUTINHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA